

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、盗んだ銀行キャッシュカードを現金自動預払機に挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は人を欺いていないから、甲に詐欺罪は成立しないが、人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上の利益を得たといえるから、甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する。
2. 甲は、乙所有の土地を甲が乙から買い受けた事実がないのに、登記申請に必要な書類を偽造して登記官に提出し、当該土地につき乙から甲への所有権移転登記をさせた。この場合、不動産の占有が甲に移ったといえるから、甲に詐欺罪が成立する。
3. 甲は、架空人である乙名義でX銀行Y支店に預金口座を開設しようと企て、乙に成り済まして預金口座を開設し、乙名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、預金通帳は口座開設に伴って発行される証書にすぎないので、甲に詐欺罪は成立しない。
4. 甲は、架空人である丙名義で預金口座を開設した上、乙に対し、「あなたの息子が交通事故を起こし、直ちに示談のお金が必要である。」とうそを言って、自ら通帳・印鑑を所持する上記口座に乙をして現金を振り込ませた。この場合、甲は、いまだ他人名義の口座に振込みを受けたにすぎないので、甲には詐欺未遂罪が成立するととどまる。
5. 甲は、生活費に窮したため、返済する意思がないのに、知人の乙に、「故郷にいる自分の父親が亡くなった。故郷に帰るお金がないので貸してほしい。」旨のうそを言って金員の借入れを申し込んだところ、乙は、そのうそを見破り、甲に返済の意思がないことを察したが、憐憫の情から、甲に現金を手渡した。この場合、乙は錯誤に陥っていないので、甲には詐欺未遂罪が成立するととどまる。

No298	詐欺罪一般		正答率
H20-20	正解	5	90%

1 誤っている

本記述では、盗んだキャッシュカードを用いて自動支払機から現金を取り出す行為について、いかなる犯罪が成立するかが問題になる。まず、詐欺罪（246条1項）は、人の錯覚を利用する犯罪であるから、本来的に人に向けて行われる犯罪であって、機械を相手とする詐欺的行為は詐欺罪を構成しない。よって、本記述前段は正しい。次に、電子計算機使用詐欺罪（246条の2）は、「電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え」なければならないが、本記述でそのような行為は行われていない。よって、本記述後段は、誤っている。なお、裁判例では、盗んだキャッシュカードを用いて自動支払機から現金を取り出す行為について、窃盗罪（235条）を構成するとしている（東京高判昭55.3.3）。

2 誤っている

判例は、登記官に対して偽造した書類で自己に所有権移転登記をさせたという事案において、詐欺罪は成立しないとしている（大判大12.11.12）。詐欺罪において、欺く行為の相手方は、その財物について事実上又は法律上財産的処分行為をなし得る権限ないし地位を有する者でなくてはならないが（最判昭45.3.26、百選Ⅱ56事件）、登記官は土地について処分する権限も地位も有しないからである。

3 誤っている

預金通帳が詐欺罪における客体にあたるかについて、判例は、預金通帳について246条1項の「財物」にあたるとし、詐欺罪が成立するとしている（最決平14.10.21、重判平14刑5事件）。その理由として、判例は、預金通帳について、それ自体として所有権の対象となり得るにとどまらず、これを利用して預金の預入れ、払戻しを受けられるなどの財産的価値を有するということを挙げている。

4 誤っている

自己が開設し管理する他人名義の銀行口座に詐取金が送金された時点で詐欺罪が既遂になるかについて、裁判例は、既遂を肯定している（大阪高判平16.12.21）。詐欺罪が既遂になるためには、財物の占有が移転する必要があるが、上記裁判例は、占有の移転を認める理由として、架空名義の口座であっても、口座を開設し管理していた被告人にとって詐取金を引き出すことはさほど困難でないということを挙げている。よって、甲には詐欺既遂罪が成立する。

5 正しい

大判大11.12.22。欺かれた対象者が錯誤に陥らなかったときの罪責について、判例は、詐欺罪において処分に向けられた欺罔行為は存在したが相手方がそれを見抜いて錯誤に陥らなかった場合は、未遂罪になるとしている。甲のうその借入れの申込みに対して、乙はそのうそを見破り錯誤に陥っていないので、甲には詐欺未遂罪が成立する。